

0004720-47.2021.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... razão da condenação anterior por tráfico de droga, que não serve para configurar maus antecedentes ou reincidência, mas é apta a evidenciar a dedicação a atividades criminosas, notadamente o tráfico de drogas. Assim, o acusado não preenche todos os requisitos legais. Pelos mesmos motivos, o regime prisional deverá ser o inicialmente fechado e se mostra incabível a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

0004720-47.2021.8.26.0269 - Controle 2021/001295

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SILVA DE MORAES

Data da Audiência:

28/04/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ausente o acusado Gabriel Silva de Moraes e a testemunha Raul Fernando de Medeiros, embora intimado às fls. 141 e requisitado, respectivamente. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foi ouvida a testemunha Gustavo Henrique Gomes arrolada pelas partes. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Raul Fernando de Medeiros, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Decreto a revelia do acusado e não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 06 de setembro de 2021, por volta das 17 horas e 40 minutos, na Rua Agides Ravaci, próximo ao nº 51, Jardim Nova Era (ou Taboãozinho), nesta cidade e Comarca de Itapetininga, trazia consigo, para fornecimento e entrega a consumo, ainda que gratuito: a) 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 42,51g (quarenta e dois gramas e cinquenta e um centigramas); b) 04 (quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 0,39g (trinta e nove centigramas), e; c) 05 (cinco) porções de crack, com peso líquido de 1,25g (um grama e vinte e cinco centigramas), sendo que agia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (fls. 85) e apresentou defesa prévia (fls. 89). A denúncia foi recebida em 22/10/2021 (fls. 90/91) e o acusado foi citado (fls. 106). Durante a

instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu não foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/13), auto de constatação (fls. 30/31) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 81/83). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu disse que havia adquirido "maconha", "crack" e "cocaína" para seu próprio consumo, pagando a importância de R\$ 190,00. Disse que não correu, nem dispensou as drogas. Outras pessoas estavam no local e fugiram, inclusive quem lhe vendeu os entorpecentes (fls. 05). Em Juízo, o réu optou pela revelia. A prova oral é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que, na data dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhando de rotina no bairro acima mencionado, instante em que foram informados por um transeunte que o acusado estaria vendendo drogas no local acima mencionado. Em razão disso, os militares resolveram averiguar. Já próximos do local, os policiais identificaram o denunciado que, ao ver a viatura, empreendeu fuga e arremessou uma sacola plástica nas proximidades. Após conseguirem deter o acusado e recuperarem a sacola que ele havia lançado, os policiais verificaram que no interior da sacola estavam as porções de entorpecentes acima mencionadas, sendo que 09 (nove) delas estavam prontas para a imediata alienação. Além das drogas, foram apreendidos com o acusado R\$ 190,00 (cento e noventa reais), valor, obviamente, proveniente das vendas anteriores à abordagem. Ante a inequívoca situação de flagrância, o acusado foi preso e conduzido a solo policial para as demais providências. Pois bem. Agora, o policial militar Gustavo afirmou que estava em patrulhamento quando um cidadão abordou a viatura e disse que indivíduos traficavam em determinado local. Foram transmitidas as características dos ditos traficantes. Então, foram averiguar. Lá chegando, abordaram dois indivíduos. O réu, antes disso, correu e dispensou uma sacola. A sacola abarcava as doses de entorpecentes descritas na denúncia. O réu também trazia consigo quantia em dinheiro. O acusado admitiu, sozinho, a prática criminosa. Assim, a prova é firme ao incriminar o acusado. Registre-se que nada está a indicar que a testemunha esteja a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. A par disso, registre-se que o acusado sequer deu-se ao trabalho de apresentar sua defesa pessoal em Juízo. Dessa forma, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu não ostenta Maus antecedentes e é primário (fls. 110/114), apesar de já ter sido condenado por tráfico de droga - sentença ainda não transitada em julgado. Na segunda fase a pena deverá ser agravada, tendo em vista o fato de o crime ter sido praticado durante período de calamidade pública causada pela pandemia de COVID-19. Cabe lembrar ser impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em razão da condenação anterior por tráfico de droga, que não serve para configurar Maus antecedentes ou reincidência, mas é apta a evidenciar a dedicação a atividades criminosas, notadamente o tráfico de drogas. Assim, o acusado não preenche todos os requisitos legais. Pelos mesmos motivos, o regime prisional deverá ser o inicialmente fechado e se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até porque não está preenchido o requisito objetivo para a substituição. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, com decretação do perdimento dos valores apreendidos. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão acusatória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. I- DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDOTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11343/06: A acusação se baseia, tão somente, em apreensão de diminuta quantidade entorpecentes e como a pessoa que foi conduzida junto com o réu à Delegacia disse desconhecer o acusado e não ter comprado entorpecentes dele (fls. 4), a conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. Ressalte-se que Alex disse que o réu passou

por ele e pediu um isqueiro emprestado, sendo que neste momento a polícia apareceu. O próprio réu esclareceu, desde o primeiro momento que foi formalmente ouvido (fls. 5), que se trata de usuário e que o entorpecente apreendido era para seu uso – versão corroborada pela testemunha Alex no sentido de que o réu lhe pediu um isqueiro (indicando que faria uso de entorpecente). A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico “para consumo pessoal”. Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do in dubio pro reo, que determinam que se presuma que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Ainda, o fato de as substâncias estarem embaladas individualmente nada indica: se alguém vende a droga fracionada, alguém a compra também fracionada, de modo não há como inferir a mercancia apenas em razão desta circunstância. Destaque-se, por fim, que o réu declarou que possuía os entorpecentes para seu consumo pessoal. De fato, o caso envolve diminuta quantidade de entorpecente, indicando se tratar de hipótese de uso. Desta maneira, diante da ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais. II- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são

subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III- TESES SUBSIDIÁRIAS. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer-se: a) a fixação da pena-base do acusado no patamar mínimo legal; b) seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixado regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos, ante a primariedade do réu e em conformidade com os arts. 33, 44 e 59 do Código Penal; c) a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, nos moldes do que estabelece o artigo 8, item 2, alínea “h”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. GABRIEL SILVA DE MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, c.c. o art. 61, inc. II, alínea “J”, do Código Penal,

porque, no dia 06 de setembro de 2021, em período de anormalidade - Pandemia, por volta das 17 h e 40 min, na Rua Agides Ravaci, próximo ao n. 51, Jardim Nova Era (Taboãozinho), nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma porção de "maconha", com peso de 42,51 gramas; quatro porções de "cocaína", com peso de 0,39 gramas; e cinco porções de "crack", com peso de 1,25 gramas. O Réu foi notificado, fls. 85, e apresentou defesa preliminar, fls. 89. A denúncia foi recebida, fls. 90/91, e o Réu, citado, fls. 106. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento foi ouvida uma testemunha. Foi decretada a revelia do Réu. Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a desclassificação e, de forma subsidiária, benefícios. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 08/10, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 11/13, bem como no Laudo de Constatação, fls. 30/31 e de Exame químico-toxicológico n. 294813/2021, fls. 81/83, constatando-se a presença dos princípios ativos cocaína e tetrahydrocannabinol (THC) (maconha). Gustavo Henrique Gomes, policial militar, testemunha, disse que estavam em patrulhamento quando receberam informações de uma pessoa que não quis se identificar, segundo a qual dois rapazes faziam o tráfico de entorpecentes; foram ao local e viram ambos e, nesse momento, o Acusado jogou uma sacola e os dois tentaram fugir, um para cada lado, mas foram abordados e, com o Acusado, houve apreensão de R\$ 74,00 e, com o outro rapaz, da quantia de R\$ 150,00. Verificaram o que havia na sacola e encontraram entorpecentes, o Acusado assumiu a propriedade e isentou a outra pessoa de responsabilidade. Confrontando-se a prova coligida e de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu era o proprietário dos entorpecentes, destinados à venda, uma vez que foi visto ao fazer contato com outra pessoa e, ao ver os policiais, jogou uma sacola dentro da qual havia uma porção de "maconha", com peso de 42,51 gramas; quatro porções de "cocaína", com peso de 0,39 gramas; e cinco porções de "crack", com peso de 1,25 gramas, entorpecentes que, pela diversidade, quantidade e forma de separação claramente eram destinados à venda. Não havia outra razão para o Réu estar naquele local, com aquela quantidade de drogas, exceto a prática do tráfico de entorpecentes. Ademais, com o Acusado houve apreensão de dinheiro, fruto da venda pretérita das drogas, o que se infere das circunstâncias e da ausência de demonstração de ocupação lícita. As testemunhas não têm motivos para incriminarem um inocente. Para que seja valorada a veracidade ou idoneidade do relato policial, não há necessidade de confirmação do apurado por pessoa estranha aos quadros da Polícia. Absurdo seria admitir-se situação contrária. Não se conhece razão plausível para que os policiais arquitetassem diabólico plano visando incriminar este Réu, apontando-a como autor dessa espécie de crime. Tudo indica que os policiais agiram com lisura e, por certo, não se poderia desacreditar o relato de cada qual, uma vez que apenas tais agentes é que presenciaram e participaram da diligência de localização da droga, não se podendo entender como suspeitos aqueles que são investidos de poder para tal função. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Não seria lógico o Estado contratar agentes para a segurança pública, investindo-os de parcela do poder estatal e, ao serem chamados a Juízo, não lhes emprestar credibilidade. Os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Destarte, o Réu trazia consigo substâncias entorpecentes, conduta esta que configura a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33,

da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do Agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Em que pese a existência de condenação pretérita, ante a ausência de trânsito em julgado, considero as circunstâncias judiciais favoráveis, assim fixo a pena - base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: A agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "j", não pode ser acolhida. Com efeito, a incidência da agravante da calamidade pública exige que o agente tenha se aproveitado consciente e voluntariamente de circunstância que implique maior gravidade, e não há nexo de causalidade entre a ofensa ao bem jurídico e a pandemia do novo coronavírus. O Réu é menor de 21 anos, logo faz jus à atenuante. Todavia, na segunda etapa, a atenuante não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". - Art. 68, do CP: Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006, é ela reservada ao "pequeno traficante", de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. Conforme se verifica às fls. 113, Certidão do Cartório Distribuidor, o Réu possui condenação, sem trânsito em julgado, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, o que permite afirmar, com certeza, que vem se dedicando a atividades criminosas, situação incompatível com a concessão do redutor. Nestes termos afastado a causa de diminuição de pena. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: Considerando-se a quantidade dos entorpecentes e a pena fixada, o regime será o inicial semiaberto. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Ausentes os requisitos, à vista da pena fixada. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar GABRIEL SILVA DE MORAES, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Sem condenação nas custas. Decreto da perda dos valores apreendidos. Deixo de condenar o Réu nas custas, ante a pobreza presumida. O Réu respondeu em liberdade ao processo, e, neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 28 de abril de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA